

1501327-34.2021.8.26.0077

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... CP. Organização criminosa e associação ao tráfico. Insuficiência probatória para o édito condenatório. Corrupção passiva em relação ao acusado Glauco.

Manutenção da absolvição por insuficiência probatória. Penas e regimes adequadamente fixados. Recursos da acusação e defensivos improvidos. Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos". (TJSP, Apelação Criminal nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1501327-34.2021.8.26.0077

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSEVAL CAETANO MARTINS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

JOSEVAL CAETANO MARTINS e ABELARDO CARNEIRO DE JESUS JUNIOR foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 171, §4º, c.c artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 2º da Lei n. 12.850/13, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de junho de 2021, por volta das 20h00min, na Rua Manoel Vieira da Silva, nº 806, Bairro Village de Fiori, nesta cidade e Comarca de Birigui, agindo em concurso e com unidade de designios, obtiveram, para si, vantagem ilícita no valor de R\$ 3.499,99 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), em prejuízo de Getúlio Alves dos Santos, idoso com 82 anos de idade, mediante o ardil abaixo descrito e empregado contra seu filho Willian Tibério dos Santos.

Consta também que, em data incerta, mas até o mês de junho de 2021, JOSEVAL CAETANO MARTINS e ABELARDO CARNEIRO DE JESUS JUNIOR integraram, pessoalmente, organização criminosa.

A denúncia foi recebida às fls. 201/204. Devidamente citados, os réus apresentaram respostas escritas à acusação às fls. 235/242 e 246/253.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima Willian, de duas testemunhas arroladas em comum com a defesa do corréu Joseval e duas testemunhas arroladas pela defesa do corréu Aberlardo, interrogando-se, posteriormente, os réus (fls. 322/323 e 337/338).

Em seus memoriais finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão e, por conseguinte, a condenação dos réus nos termos da denúncia ofertada. Requereu a aplicação das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "h" e "j", do CP e da atenuante da confissão, pugnando quanto ao réu Abelardo a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Pugnou ainda, pela aplicação da causa de aumento prevista no §4º, do artigo 171, do CP, do concurso material de crimes, a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento das penas, a impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou sursis processual, a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como a fixação de valor dos danos causados pela infração (fls. 376/382).

A Defesa do corréu Aberlardo ofereceu seus memoriais às fls. 389/394, requerendo a absolvição do réu. Em caso de condenação pelo crime de estelionato, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação das atenuantes da confissão e menoridade relativa do réu, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §4º, do artigo 171 do CP, o reconhecimento do arrependimento posterior e da participação de menor importância do réu, a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena e a concessão do sursis processual.

A defesa do corréu Joseval apresentou memoriais finais às fls. 435/439, requerendo a absolvição do réu no tocante ao crime de organização criminosa. Em caso de condenação pelo crime de estelionato, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §4º, do artigo 171 do CP e a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é parcialmente procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução processual penal, a materialidade do crime de estelionato restou demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 25/28 e 32/33, auto de exibição e apreensão de fls. 29/30, documento de fl. 31, laudos máquinas cartões de crédito de fls. 254/274, laudo pericial celular de fls. 275/277, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

Da mesma forma, a autoria é certa e inquestionável.

Interrogado em juízo, o réu Abelardo afirmou ter sido convidado por Joseval para retirar o cartão bancário na residência da vítima de forma ilícita, e por enfrentar dificuldades financeiras, decidiu aceitar. Sobre a dinâmica dos fatos, relatou: "Chegando lá, nós parou o carro, o senhor Willian entregou o cartão na nossa mão. Nós falou para ele que se ele quisesse ele podia levar amanhã no banco, mas ele preferiu entregar na nossa mão e nós saiu. Passando em Botucatu, nós passou o cartão e foi embora, só que aí os policiais pegou nós na rodovia".

Ao ser questionado, o depoente declarou que Joseval o convidou para ir até a cidade de Birigui, oportunidade em que Joseval esclareceu sobre o golpe a ser aplicado, acrescentando não saber para quem Joseval entregaria os cartões na cidade de São Paulo. Afirmou que ganharia a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais), declarando que Joseval recebeu uma ligação telefônica ordenando que o cartão da vítima fosse passado na máquina.

Informou que estava na companhia de Joseval no momento em que a vítima Willian entregou o cartão, informando ter percebido que Willian tirou foto do automóvel utilizado no ilícito. Informou, ainda, que estavam na posse de 04 máquinas de cartão, não se recordando em qual delas utilizou o cartão da vítima.

Indagado, o réu negou ter sido processado criminalmente, acrescentando ser casado e possuir filhos, além de trabalhar eventualmente em um bar com seu genitor. Alegou ter sido a única vez que praticou o crime de estelionato, negando ter realizado qualquer ligação telefônica através de seu aparelho celular.

O depoente alegou ter orientando a vítima para que entregasse o cartão ao Banco por estar arrependido, mas Willian insistiu para que os réus retirassem o objeto. Negou ter recebido qualquer quantia em dinheiro pelo serviço, afirmando ter sido obrigado a utilizar no cartão da vítima no meio do trajeto de volta para São Paulo. Por fim, declarou residir com o genitor, negando conhecer o indivíduo "Felipe baianinho". Em seu interrogatório, o réu Joseval confessou ter se dirigido à cidade de Birigui para retirar o cartão bancário de forma ilícita, acrescentando ter convidado Abelardo para lhe fazer companhia, esclarecendo ao corréu o motivo da viagem durante o trajeto. O réu declarou que após retirar o cartão bancário na residência da vítima, retornou à cidade de São Paulo.

Relatou que durante o trajeto foram abordados pela polícia militar, acrescentando ter ficado muito nervoso por nunca ter praticado tal fato. Sobre o depoimento prestado em solo policial o depoente narrou: "Na verdade eu tive que dar um nome porque eu tava bem coagido mesmo. Assim que eu cheguei à delegacia, o policial falou: A mãe do delegado caiu num golpe desse, você acha que ele tá feliz? E já entrou com a gente bem firme mesmo. Então assim, eu não encontrei com ninguém. Essas maquininhas eles mandaram pra mim por um moto boy na rua Barão de Jaguar mesmo, no dia da viagem. Eu encontrei esse moto boy, peguei as maquininhas e peguei o Abelardo depois e a gente foi. Mas eu não conheço esse Felipe ou "baianinho", foi porque ele pegou "BH" no meu celular e ele falou que era "baianinho" porque ele tinha já caído num golpe assim".

Ao ser questionado, o depoente relatou que um motorista de aplicativo com o qual trabalha o contratou para buscar o cartão bancário na cidade de Birigui. Informou ter sido processado pelo mesmo fato em razão de ter realizado uma corrida com o mesmo indivíduo que o contratou com o fim de buscar cartão bancário.

Negou ter conhecimento acerca da dinâmica de uma possível organização criminoso, acrescentando que foi contratado para retirar o cartão na residência da vítima. Indagado, afirmou que um indivíduo iria retirar o cartão da vítima na Rua Barão de Jaguar, revelando que durante o caminho de volta para São Paulo recebeu a ordem para passar o cartão bancário no valor de R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em uma das máquinas que estavam em sua posse, porém não tem conhecimento sobre outras informações.

Revelou ter sido contratado pelo valor de R\$500,00 (quinhentos reais), narrando: "A gente não ia passar na maquininha, só que ele pediu pra passar antes, porque deve ter acontecido algum problema, depois disso eu vim reconhecer que eles mandaram passar porque o Willian desconfiou que tinha caído em um golpe. Acho que para não perder tempo, o rapaz mandou passar e a gente passou porque já tava com o cartão e já tinha recebido os R\$500,00 (quinhentos reais) [...] O "BH" ficou porque ele tinha pegado meu celular e ele falou que deve ser de vulgo "baianinho" e eu falei Felipe porque tinha que falar alguma coisa na hora, mas o rapaz que eu peguei no UBER ele sempre falou pra eu chamar de "BH" [...] Foi esse daí do senhor Getúlio

[...] Não a gente pegou e foi embora, só que o delegado falou que já tinham feito esses golpes em Botucatu, só que a gente nem entrou em Botucatu [...] Em Aramina foi quando eu fui com esse "BH" que eu deixei ele lá e voltei, foi a primeira vez que falei pro senhor. Fui solto no mesmo dia".

O depoente declarou que por necessitar de dinheiro para quitar uma dívida com um agiota, decidiu retirar o cartão bancário da vítima Getúlio, acrescentando que Abelardo só participou uma única vez. Afirmou que retirava o cartão da vítima e entregava ao indivíduo vulgo "BH", mas não tinha conhecimento sobre outras ações que tal indivíduo realizava posteriormente.

Por sua vez, ouvida na Delegacia polícia, a vítima Getúlio Alves dos Santos (82 anos de idade) foi ouvida apenas na Delegacia de Polícia (fls. 154), narrou: "recebeu uma ligação em seu telefone fixo e passou para seu filho conversar, posteriormente uma pessoa compareceu em sua residência e acabou entregando o seu cartão Visa Ourocard, pois disseram que iriam levar o cartão até a perícia do banco para que pudessem fazer o bloqueio e estorno, o indivíduo estava acompanhado de uma mulher, que não os conseguiu visualizá-los direito, estavam utilizando o veículo Ford/Ka, placa QWV3455, de cor preta. Posteriormente, foi efetuado uma compra no valor de aproximadamente R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). O seu filho Willian Tiberio dos Santos, é o seu procurador, pois o declarante possui deficiência física e alguns problemas de saúde, quem cuida de tudo é o seu filho Willian. Logo que perceberam que se tratava de um golpe, de prontidão efetuaram o registro do boletim de ocorrência e solicitaram o bloqueio do cartão. Neste ato, representa criminalmente contra os autores quando vierem a serem identificados".

Sobre a dinâmica dos fatos, Willian, o filho da vítima relatou: "Ligaram em casa se passando pelo banco perguntando pro meu pai se ele era Getúlio Alves dos Santos, que era do banco do Brasil, FEBRABAN, salvo engano, se havia sido feita uma compra em São Paulo [...] Então foi eu que acabei conversando com esses indivíduos, era muito similar ao banco, não sei como eles fizeram isso para a gente caiu nesse golpe aí. A gente foi induzido a erro mesmo [...] E aí eles se passaram pelo banco e falaram se havia feito essa compra e eu falei que não [...] Que então a gente tinha que ligar no 0800 do cartão para tentar bloquear essa compra, algo assim. E foi o que a gente fez e entrou nesse sistema que é muito idêntico ao do banco. Aí fiquei bastante tempo conversando. Tentei falar com o gerente, mas não consegui porque tava fora do expediente [...] Aí eles disseram que teria que cortar o cartão e entregar pra um correspondente do banco que ia passar em casa se a gente autorizava, para poder checar que o cartão estava conosco. E que não precisava da tarja, só o chip para poder fazer essa checagem no banco. Aí eu falei pro meu pai, expliquei a situação e ele falou que era melhor entregar [...] Então esse pessoal acabou enviando duas pessoas em um veículo preto, eu acabei filmando a placa do carro enquanto meu pai entregava o cartão [...] Alguns minutos depois, começaram a cair compras. Tentei ligar, mas acho que eles bloquearam o telefone de casa, aí fui pra casa da minha namorada e de lá eu consegui ligar pro banco e bloquear, mas já tinham feito compras [...] Imediatamente fui à delegacia fazer Boletim de ocorrência".

Relatou que durante a madrugada, dois policiais militares rodoviários chegaram a sua residência informando sobre a detenção de dois indivíduos em um carro preto, os quais estavam com algumas máquinas de cartões bancários, bem como um pedaço do cartão bancário da vítima Getúlio, oportunidade em que exibiu a filmagem que realizou no momento da entrega do cartão de seu genitor.

Ao ser questionada, a vítima relatou que os policiais militares identificaram o veículo exibido nas imagens como sendo o mesmo conduzido na rodovia com os indivíduos. Declarou que não obteve prejuízo financeiro em razão de um seguro que possui junto à instituição financeira, asseverando que o cartão bancário foi entregue pelo senhor Getúlio, oportunidade em que permaneceu filmando a ação criminosa.

Afirmou que os indivíduos chegaram à residência afirmando serem correspondentes bancários e estavam no local para retirar o cartão da vítima. Declarou que após o golpe, o telefone da residência não efetuava ligações, não sabendo informar se os criminosos bloquearam a linha momentaneamente. Afirmou que seu genitor possui 82 anos de idade e sofre com diversos problemas de saúde, acrescentando ser responsável legal pelo pai há aproximadamente dez anos.

Relatou que seu genitor atendeu a ligação telefônica, porém, como é procurador de Getúlio assumiu a ligação e realizou as tratativas com os criminosos. Asseverou que o genitor estava em sua companhia quando os policiais militares chegaram à residência, acrescentando que o indivíduo que estava conduzindo o veículo era de cor branca e rosto redondo, aparentando ter entre 35 e 40 anos.

Segundo o depoente, os policiais militares reconheceram a placa do veículo através das imagens exibidas pelo depoente, não tendo condições de afirmar o sexo do passageiro do veículo porque a pessoa utilizava máscara de proteção e estava escuro, revelando que uma mulher se passou pela atendente do Banco na primeira vez em que tentou ligar com o gerente do banco.

Negou ter afirmado na Delegacia de Polícia que o passageiro do veículo era do sexo feminino, acrescentando que a ação criminosa foi rápida e que os réus permaneceram no veículo no momento da retirada do cartão. Por fim, o depoente afirmou novamente que o cartão foi entregue aos criminosos pelo seu genitor.

O policial militar Antônio da Silva Duarte Neto relatou que na data dos fatos estava em patrulhamento pela Rodovia Castelo Branco, oportunidade em que decidiu abordar o veículo conduzido por Joseval. Ao proceder a abordagem, o depoente localizou duas máquinas de cartão bancários debaixo do banco do passageiro, além de outras da quantia de R\$1.700,00 (mil setecentos reais) e mais duas máquinas de cartão no interior da mochila de Joseval.

Relatou que os indivíduos apresentaram versões diversas sobre o motivo que os levaram à cidade de Birigui, razão pela qual decidiu entrar em contato com policiais militares da região de Araçatuba, que por sua vez descobriram que uma pessoa havia registrado um boletim de ocorrência de estelionato praticado contra um idoso. Declarou que o filho do idoso filmou o veículo utilizado pelos criminosos no momento do golpe, e através das imagens conseguiu identificar os indivíduos.

De posse das informações, o depoente relatou que os indivíduos confessaram a prática do crime, revelando ainda, integrarem uma quadrilha que aplicava esse tipo de golpe, informando que as pessoas, entre elas mulheres, têm funções diversas e induzem as pessoas a acreditarem que o cartão bancário foi utilizado, sendo que para cancelar a compra realizada, a vítima precisa entregar o cartão para o suposto correspondente bancário proceder ao cancelamento.

Relatou que cada membro da quadrilha recebe uma porcentagem sobre as transações realizadas, a depender da função exercida, acrescentando que os réus confessaram que praticarão o mesmo crime em outras cidades da região. Ao ser questionado, o policial declarou que as organizações criminosas procuram pessoas vulneráveis para aplicar os golpes.

Indagada, a testemunha afirmou que os indivíduos foram questionados separadamente para aferir a veracidade das informações fornecidas pelos abordados, afirmando que os próprios indivíduos confessaram a participação em uma quadrilha. O depoente declarou que os indivíduos tinham a função de retirar os cartões bancários nas residências das vítimas, relatando que Abelardo também confessou a prática do estelionato.

No mesmo sentido foi a declaração do policial militar André Cristiano de Almeida. As testemunhas de defesa do corréu Abelardo, Carolina Faria Fernandes e Cassia

Gomes Ribeiro não presenciaram os fatos e afirmaram que Abelardo é uma pessoa estudiosa, tranquila e trabalhadora, negando saber sobre o envolvimento do réu com o crime.

Pois bem. Conforme se observa, o ardil utilizado pelos réus para obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima restou cabalmente demonstrado nos autos, sendo que os réus, agindo em conluio, se dirigiram à residência de Getúlio com o objetivo de retirar o cartão bancário após tê-lo induzido a erro através de ligação telefônica efetuada por terceira pessoa, fazendo a vítima acreditar na necessidade da entrega do cartão para o cancelamento de uma suposta compra realizada.

O golpe aplicado pelos réus proporcionou vantagem ilícita, na ocasião em que os réus utilizaram o cartão em máquina, realizando uma compra fraudulenta no valor de R\$ 3.499,99 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) (cf. comprovante às fls. 31).

No caso vertente, os réus confessaram judicialmente a prática do estelionato, sendo que tais declarações foram corroboradas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atuaram na ocorrência, os quais foram coerentes e uníssomos confirmando os fatos narrados na peça acusatória, demonstrando o ardil utilizado pelos réus para a obtenção de vantagem ilícita.

Nesse sentido: "Prova. Estelionato. Palavra da vítima e de testemunha. Eficácia. Tratando-se de estelionato, as palavras da vítima e de testemunha asseguram a autoria do delito quando não há nenhum motivo plausível para efetuarem tal acusação e se verifica que o réu, através de subterfúgios, iludiu o ofendido, obtendo substancial lucro em seu prejuízo" (TACRIM-SP 6ª C. Ap.133.715-7/5 rel. Almeida Sampaio j. 16.06.2003 Rolo/flash 2008/261). (TJSP -Apelação nº 0000127-85.2010.8.26.0066. Rel. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. m 19.05.2014).

Com efeito, a cabal comprovação da fraude promovida pelos réus (ir à residência da vítima e engana-las - passando-se por funcionários de empresas de cartões de crédito/correspondentes bancários - retirando os cartões bancários, utilizando-os nas máquinas de cartões que levavam consigo, e, posteriormente, sacando o dinheiro nas agências bancárias ou efetuando compras) - encontra-se demonstrada pelos documentos acostados a fl. 29/31 (auto de exibição e apreensão das máquinas de cartões e comprovante de compra efetuada com o cartão da vítima na função crédito) e fls. 254/274 (laudo pericial das máquinas apreendidas com os réus comprovando as transações efetuadas), restando evidente a manobra fraudulenta empregada pelos réus contra a vítima idosa.

Nesse raciocínio, o dolo restou bem configurado, vez que a vítima Getúlio efetuou a entrega do cartão - o que foi confirmado pela vítima Willian, a qual registrou a ação criminosa, fornecendo a placa do veículo através de imagens de celular - ao passo que os réus retiraram o cartão em questão e foram surpreendidos em poder de quatro máquinas de cartões utilizadas para concluir a fraude, além de razoável quantia em dinheiro. (fls. 29/30 e 225).

Como é cediço, o dolo constitui elemento subjetivo do delito previsto no artigo 171, do Código Penal. Nesse sentido, Julio Fabbrini Mirabete, na obra "Manual de Direito Penal - vol. 2", Ed. Atlas, ensina: "O dolo do estelionato é a vontade de praticar a conduta, consciente o agente que está iludindo a vítima. Exige-se o elemento subjetivo do injusto (dolo específico) que é a vontade de obter ilícita vantagem patrimonial para si ou para outrem. Sem a consciência da ilicitude da locupletação não há estelionato."

Nesse mesmo entendimento: "É necessário que o sujeito tenha consciência da ilicitude da vantagem que obtém da vítima. O tipo requer um segundo elemento subjetivo, contido na expressão para si ou para outrem.". (RT 720/532).

Por outro lado, o delito tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 não restou comprovado nos autos.

Isso porque, além da negativa dos réus em juízo, a configuração do tipo penal em apreço exige que ao menos quatro pessoas se unam de forma estável e permanente com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 04 anos, ou que sejam de caráter transnacional.

É a constatação desse vínculo subjetivo duradouro que se presta a distinguir o mero concurso eventual e episódico de pessoas do crime autônomo em tela.

Conforme leciona RENATO BRASILEIRO DE LIMA: “a) Associação de 4 (quatro) ou mais pessoas: esta associação de 4 (quatro) ou mais pessoas deve apresentar estabilidade ou permanência, características relevantes para a configuração, que diferenciam esta figura delituosa do concurso eventual de agentes a que se refere o art. 29 do CP, dotado de natureza efêmera e passageira. Por certo, apesar de não haver menção expressa no art. 2º da Lei nº 12.850/13, o ideal é concluir que a estabilidade e a permanência funcionam como elementares implícitas no crime de organização criminosa, porquanto não se pode admitir que uma simples coparticipação criminosa ou um eventual e efêmero acordo de vontades para a prática de determinado crime tenha o condão de tipificar tal delito”. (Legislação criminal especial comentada: volume único 9. ed.Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 788).

No caso concreto, o vínculo associativo estável, duradouro e permanente entre os réus e ao menos outros dois comparsas, não foi devidamente comprovado, de forma que a simples menção do nome de um indivíduo em solo policial, não é suficiente para configurar o crime.

Outrossim, é nítido que não houve uma aprofundamento nas investigações com o objetivo de apurar a existência de uma *societas sceleris* entre os réus, a fim de se concluir pela configuração do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Salvo melhor juízo, os elementos coligidos nos laudos periciais (fls. 254/274 e 275/277) e no relatório de investigação (fl. 155/156) e a prova oral supra colhida não são suficientes para comprovar a estabilidade e a permanência do agrupamento, parte dos seus membros (ao menos quatro), a função desempenhada por cada membro, embora não se exija a habitualidade no cometimento reiterado das infrações penais. Dito isso, a associação não pode ser extraída de um fato isolado, requerendo, para sua comprovação, investigação mais aprofundada e conclusiva. Isso posto, diante da insuficiência probatória, impõe-se a absolvição dos réus pela prática do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, por força do princípio do *in dubio pro reo*.

Nesse mesmo entendimento: “APELAÇÃO. Peculato e corrupção passiva. Recursos da acusação e das defesas. Preliminares. Inépcia da denúncia. Violação do princípio do promotor natural. Não ocorrência. Preliminares rejeitadas. Mérito. Prova. Autoria e materialidade demonstradas. Manutenção da condenação da condenação dos réus Renato e Wagner pelo crime do artigo 317, § 1.º, do CP, em continuidade delitiva, e do acusado Glauco pelo delito do artigo 312 do CP. Organização criminosa e associação ao tráfico. Insuficiência probatória para o édito condenatório. Corrupção passiva em relação ao acusado Glauco. Manutenção da absolvição por insuficiência probatória. Penas e regimes adequadamente fixados. Recursos da acusação e defensivos improvidos. Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos”. (TJSP, Apelação Criminal nº 0027911-77.2016.8.26.0114, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j.24.08.2020).

Anoto, por oportuno, ser incabível a aplicação do artigo 16, do Código Penal (arrependimento posterior), pois consoante se verifica do arcabouço probatório, apesar de ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, os réus não repararam o dano ou restituíram a coisa até o recebimento da denúncia, por ato voluntário.

Tampouco restou comprovado que os réus só aceitaram retirar o cartão da vítima após insistência dela, como alega a combativa defesa, valendo lembrar que a vítima foi categórica ao afirmar que os réus chegaram ao local se identificando como correspondentes bancários e solicitando a entrega do objeto.

Por outro lado, no caso em tela deverá incidir o §4º, do artigo 171, uma vez que a vítima Getúlio – a qual era proprietário do cartão e o entregou aos réus, consoante devidamente comprovado pelo depoimento da vítima Willian – que possuía, à época do fato, 82 anos de idade, configurando a causa de aumento de pena em tela.

Por derradeiro, o conjunto probatório revela que a atuação de cada um dos réus foi relevante para o êxito da empreitada criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância do corréu Abelardo.

“Quem vigia nas imediações para garantir o êxito do furto é coautor, não sendo sua participação de menor importância”. (TACrSP 20/102).

Demonstradas, portanto, a materialidade e autoria delitivas, um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria das penas.
JOSEVAL CAETANO MARTINS.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias não são desfavoráveis. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase de fixação da pena, reapreciando entendimento anterior adotado por esse juízo, incabível a agravante prevista no art. 61, inc. “j”, do Código Penal, eis que não restou devidamente comprovado nos autos que a réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do COVID-19.

Nesse mesmo entendimento: "APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes com a recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminosa e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1512067-20.2020.8.26.0228, Rel, Des. Andrade Sampaio, v.u., j. 12.02.2021).

Outrossim, não deve incidir a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” (crime cometido contra idoso), do Código Penal, sob pena de configurar bis in idem, uma vez que tal condição será utilizada para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria.

Por outro lado, embora o réu tenha confessado o delito, certo é que a pena-base foi fixada no mínimo legal, atraindo a aplicação da Súmula 231 do STJ, mantendo-se a reprimenda inalterada.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no § 4º do artigo 171, do Código Penal, majoro a pena em 1/2, perfazendo 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O réu é primário e a pena fixada é inferior a quatro anos, razão pela qual fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Na ausência de casa do albergado ou estabelecimento adequado para execução da pena, estas poderão ser cumpridas em regime de albergue domiciliar.

O réu poderá recorrer em liberdade, porquanto foi beneficiado com a liberdade provisória, conforme fls. 337/338.
ABELARDO CARNEIRO DE JESUS JUNIOR.

Analizadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias não são desfavoráveis. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase de fixação da pena, reapreciando entendimento anterior adotado por esse juízo, incabível a agravante prevista no art. 61, inc. "j", do Código Penal, eis que não restou devidamente comprovado nos autos que a réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do COVID-19.

Nesse mesmo entendimento: "APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes com a recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminosa e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1512067-20.2020.8.26.0228, Rel. Des. Andrade Sampaio, v.u., j. 12.02.2021).

Outrossim, não deve incidir a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h" (crime cometido contra idoso), do Código Penal, sob pena de configurar bis in idem, uma vez que tal condição será utilizada para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria.

Por outro lado, embora o réu tenha confessado o delito e fosse menor de 21 anos à época do fato, certo é que a pena-base foi fixada no mínimo legal, atraindo a aplicação da Súmula 231 do STJ, mantendo-se a reprimenda inalterada.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no § 4º do artigo 171, do Código Penal, majoro a pena em 1/2, atingindo 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O réu é primário e a pena fixada é inferior a quatro anos, razão pela qual fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Na ausência de casa do albergado ou estabelecimento adequado para execução da pena, estas poderão ser cumpridas em regime de albergue domiciliar.

O réu poderá recorrer em liberdade, porquanto foi beneficiado com a liberdade

provisória, conforme fls. 337/338.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

1) CONDENAR JOSEVAL CAETANO MARTINS e ABELARDO CARNEIRO DE JESUS JUNIOR, qualificados nos autos, como incurso no artigo 171, §4º, c.c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal.

2) ABSOLVER JOSEVAL CAETANO MARTINS e ABELARDO CARNEIRO DE JESUS JUNIOR, qualificados nos autos, da prática do delito previsto no artigo 2º, da Lei 12.850/13, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Os réus preenchem os requisitos para a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, previstos no artigo 44, do Código Penal. A pena aplicada não é superior a quatro anos e o delito praticado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, razão pela qual as penas alternativas mostram-se socialmente recomendáveis para os réus, primários e de bons antecedentes.

Tendo em vista que os réus foram condenados à pena superior a um ano, com fundamento no § 2º, do referido artigo, substituo as penas privativas de liberdade impostas por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor correspondente a um salário mínimo, a ser paga em favor de entidade a ser especificada pelo juízo da execução e prestação de serviços à comunidade pela mesma duração da pena substituída, em entidade a ser oportunamente indicada pelo juízo da execução penal.

Na hipótese de descumprimento injustificado das restrições acima impostas, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime aberto. Os réus poderão recorrer em liberdade, eis que foram beneficiados com a liberdade provisória e tiveram a pena substituída.

Condeno o réu nas custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar valor mínimo para indenização, devendo ser aforada a ação cível adequada.

Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

P.R.I.

Birigui, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA